

1501171-61.2021.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... voltada para a prática de crime de tráfico de drogas para a obtenção de lucro fácil, tanto que já foi preso outras duas vezes pelo mesmo crime, conforme certidão de fls. 37/38;

motivos: o réu agiu movido pela ânsia do lucro fácil, ou seja, são os motivos normais de crimes de tráfico de entorpecentes;

circunstâncias: não há prova de que o réu estivesse agindo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro - SP - cep 14706-136

1501171-61.2021.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501171-61.2021.8.26.0072

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON EDUARDO GABRIEL MARCULINO

Juiz de Direito: LUIZ FERNANDO SILVA OLIVEIRA

Vistos.

I - RELATÓRIO

O Ministério Público ajuizou denúncia contra Jackson Eduardo Gabriel Marculino, qualificados nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 3 de junho de 2021, por volta de 22:00 horas, na Rua José de Almeida, nº 122, Santa Terezinha, em Bebedouro/SP, o réu trazia consigo para fim de tráfico, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, e nas mesmas circunstâncias de dia, hora e local, o réu opôs-se à execução de ato legal de agente público, mediante violência;

Segundo a denúncia, os policiais militares estavam em patrulhamento e quando o réu avistou a viatura imediatamente empreendeu fuga, saltando muros e telhados;

Diante dessa situação, os policiais perseguiram-no, e alcançaram-no, e conseguiram detê-lo no quintal de uma residência;

Na ocasião, o réu estava de posse de uma pochete de cor preta, dentro da qual havia 103 pinos de cocaína, 16 porções de maconha, R\$99,00 em espécie e um rádio HT;

No momento da abordagem, o réu ofereceu resistência, e se jogou contra o policial

Augusto, na tentativa de tomar-lhe a arma, e ambos rolaram no chão, em luta corporal.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e a final, a sua condenação com fulcro no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 329 do Código Penal.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, contendo o auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), auto de constatação provisória (fls. 11/14). Laudo toxicológico definitivo (fls. 79/81).

Defesa prévia (fls. 95/99).

Recebimento da denúncia (fls. 137/139).

Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 165/166).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 168/173), onde o parquet requereu a condenação, nos exatos termos da denúncia.

Alegações finais da defesa (fls. 180/191), com as seguintes teses: a) insuficiência de provas para a condenação; b) desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo está em ordem, sem vícios, e pronto para a decisão. As partes não alegaram qualquer questão processual, e não existem arguições de preliminares, razão pela qual adentro diretamente no mérito da causa.

Da imputação do tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

A materialidade delitiva vem consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, no auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), auto de constatação provisória (fls. 11/14), laudo toxicológico definitivo (fls. 79/81) e no depoimento das testemunhas, os policiais militares que atuaram na ocorrência policial, em razão da grande quantidade de pinos de cocaína apreendidos pela polícia, e de ter também em poder do réu as 16 porções de maconha, o que significa que ele servia a usuários diversos.

Reforça a materialidade delitiva o fato de o réu ter sido preso na posse de um rádio HT, que é um aparelho comumente utilizado por traficantes desta cidade de Bebedouro/SP, em situações onde um traficante fica com a droga para entregá-la aos usuários e outro fica em local que lhe permite avistar a aproximação de viatura policial para dar o aviso e evitar a prisão e apreensão da droga.

Nessa medida, está configurado o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O policial militar Fausto Luiz Azevedo atuou na ocorrência e afirmou que juízo que o local era conhecido por ser ponto de venda de drogas, e que ao notar a aproximação da viatura, o réu correu, pulou muros e telhados, mas acabou sendo alcançado e abordado, e com ele havia uma pochete contendo a droga apreendida.

O policial militar Guilherme Augusto da Silva Manoel confirmou a versão do policial Fausto, e com isso, está comprovada a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente imputada ao réu.

A harmonia entre os depoimentos dos policiais, e a confirmação da mesma versão dos depoimentos dos agentes públicos por ocasião do auto de prisão em flagrante delito torna a prova robusta, sem qualquer mácula, e nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme a decisão abaixo transcrita:

"Tráfico de entorpecentes Agente que traz consigo e tem em depósito 6,9 gramas de cocaína sob a forma de "crack" (22 pedras), 1,8 gramas de cocaína em pó (04 microtubos) e 1,6 gramas de maconha (01 porção) Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As

declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da pena Reprimenda benevolmente fixada Manutenção ante a ausência de apelo por parte do Ministério Público

Não há como corrigir-se pena benevolmente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Agente reincidente Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06

O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício, consta a primariedade do agente.

Pena Regime inicial Tráfico de entorpecentes Imposição legal do sistema fechado para início do cumprimento de pena Não subsistência do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 Entendimento da Resolução n. 5/2012 do Senado Federal Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, § 3º e 59, do CP O entendimento predominante nos tribunais tem sido no sentido de que, em se cuidando de tráfico de entorpecentes, não mais subsiste a vedação legal (art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado. O entendimento lastrea-se no fato do Senado Federal ter editado a Resolução n. 5/2012, pela qual cessou a executoriedade da proibição da conversão da pena de prisão imposta em mera restrição de direitos. Se não mais existe óbice à referida conversão, com muito mais razão não se poderia subtrair do Magistrado a ampla liberdade na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. O regime inicial para cumprimento de pena continua, todavia, sendo fixado consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remissão o art. 33, § 3º, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando o sentenciado deverá preencher não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva.

Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento aos requisitos contidos nos incisos I e III, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP. Não bastasse isso, ainda que o réu seja primário, descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal." (Apelação Criminal 1512927-70.2019.8.26.0320. Comarca: Limeira. 9ª Câmara de Direito Criminal do TJSP Relator: ROBERTO GRASSI NETO. Julgado em 16.05.2022) (grifei)

A defesa alega que não há provas suficientes da autoria, porém, a droga foi apreendida na pochete que estava com o réu quando de sua abordagem, e pela quantidade, e por serem duas as espécies de drogas, e porque o réu estava portando um rádio HT, isso demonstra que ele estava traficando, porque o rádio HT é utilizado para o traficante receber informações da aproximação de viaturas policiais.

Portanto, a prova é robusta a dar supedâneo ao decreto condenatório pela traficância e rejeito a tese defensiva.

A defesa construiu a tese de que a droga era utilizada para o consumo próprio e pediu a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06, todavia, a grande quantidade traduz traficância, e o local onde houve a abordagem é um ponto de venda de drogas, o que inviabiliza concluir que a droga era destinada ao consumo pessoal.

Além disso, o rádio HT apreendido com o réu é um aparelho utilizado por traficantes para se comunicarem com o "vigia", que está em local estratégico para observar a

chegada da polícia, o que significa que a conduta do réu é de traficância, sendo incabível a desclassificação para o tipo penal do art. 28, caput, da Lei 11.343/06. Por fim, na delegacia o réu afirmou que a droga não lhe pertencia, daí, ser incabível acolher a tese de que ele era o proprietário da droga para o consumo pessoal e rejeito a tese defensiva.

2. Da imputação do tipo penal do art. 329 do Código Penal

Consta da denúncia que no momento da abordagem o réu investiu-se contra os milicianos e acabou rolando no chão com o policial Augusto, todavia, essa situação não restou bem demonstrada nos autos, e não se sabe se o réu partiu para cima do policial para agredi-lo, ou se ele tentou correr e o policial pulou em cima de seu corpo para agarrá-lo, razão pela qual, na dúvida, aplico o in dubio pro reo para absolvê-lo desse crime.

3. Dosagem da pena

1ª fase: quanto às circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06:

culpabilidade: o réu agiu consciente da ilicitude de sua conduta, e praticou o crime a fim de obter lucro fácil, mediante comportamento ilícito;

antecedentes: o réu possui antecedentes criminais, porém não serão considerados nesta fase da fixação da pena;

conduta social: sem informações desabonadoras;

personalidade do agente: o réu tem personalidade voltada para a prática de crime de tráfico de drogas para a obtenção de lucro fácil, tanto que já foi preso outras duas vezes pelo mesmo crime, conforme certidão de fls. 37/38;

motivos: o réu agiu movido pela ânsia do lucro fácil, ou seja, são os motivos normais de crimes de tráfico de entorpecentes;

circunstâncias: não há prova de que o réu estivesse agindo em concurso de agentes, todavia, o fato de estar portando um rádio HT significa que outrem estava agindo como "vigia", para informar-lhe da aproximação de viaturas policiais e isso significa profissionalidade no crime;

consequências do crime: o prejuízo para a saúde pública, considerada crime de perigo concreto indeterminado ou indireto e a grande instabilidade social causada pelo tráfico de drogas, porque muitas e muitas famílias sofrem com a dependência de seus membros, e no caso concreto, o réu estava vendendo duas espécies de drogas, servindo a público variado, com profissionalidade, em razão do rádio HT, e com isso, agindo de forma profissional para destruir a vida de quantidade imensurável de pessoas;

comportamento da vítima: por se tratar de delito contra a saúde pública, a sociedade não teve parcela de contribuição para a prática do delito, não sendo o caso de reconhecimento da co-culpabilidade.

Sopesadas, detalhadamente, as circunstâncias do art. 59 do CP, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase: não há atenuantes e está configurada a agravante da reincidência, conforme certidão de fls. 37/38, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), que corresponde a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 116 dias-multa.

3ª fase: inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.

Não é o caso de aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, porque o réu é reincidente.

Sendo assim, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 716 dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo na data do fato).

Em razão da reincidência, o cumprimento de pena será no regime inicialmente fechado, na forma da Lei 8.072/90, e pelo mesmo fundamento, não é o caso de conceder ao réu as benesses dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, nos seguintes termos:

Absolvo o réu da imputação do art. 329 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;

Condeno o réu JACKSON EDUARDO GABRIEL MARCULINO, com fundamento no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c Lei 8.082/90, e aplico-lhe pena provativa de liberdade de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, e 716 dias-multa, fixados no mínimo legal;

Suspendo os direitos políticos do réu, com fundamento no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, devendo o Cartório comunicar a Justiça Eleitoral após o trânsito em julgado;

Mantenho o réu preso, pelos mesmos fundamentos da prisão preventiva e também porque, agora, condenado, poderá evadir-se do distrito da culpa, inviabilizando a aplicação da Lei Penal;

Expeça-se guia de execução provisória, nos termos da Súmula 716 do STF, constando expressamente o direito à detração penal, na forma da Lei;

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Livro Rol dos Culpados;

Custas, na forma da lei.

P.I.

Bebedouro, 17 de maio de 2022.